

1500874-81.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN GABRIEL DE CASTILHO SOUZA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra JONATHAN GABRIEL DE CASTILHO SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, cumulado com artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

A ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1500874-81.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1500874-81.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN GABRIEL DE CASTILHO SOUZA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra JONATHAN GABRIEL DE CASTILHO SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, cumulado com artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 02/04) narra que o réu, no dia 15 de março de 2021, por volta das 15:45 horas, na Praça localizada no Jardim União, na Avenida Olga Pogetti Vieira, altura do numeral 01, com Avenida Vereador Rossi Filho, no Jardim União, Valinhos/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de venda ou entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 19 (dezenove) porções de cocaína e 15 (quinze) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", apreendidas conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo (exame químico toxicológico).

Consta que os Guardas Municipais Bruno Lima Medeiros e Jesuíno Honório Pereira, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina pelo Jardim União, quando receberam uma denúncia anônima no sentido de que indivíduos estavam comercializando entorpecentes na Praça do Bairro, razão pela qual decidiram rumar até o local, e quando lá chegaram avistaram um grupo de pessoas, que ao perceber a presença da viatura, tentaram se evadir, mas foram perseguidas pelos agentes.

Consta mais que o Guarda Municipal Bruno Lima Medeiros saiu ao encalço do acusado, pois ele trazia em suas mãos uma sacolinha plástica, a qual dispensou enquanto tentava fugir, dirigindo-se à Rua Olga Pogete Vieira, local em que foi abordado. Após realizar buscar pelo local em que o acusado dispensou a sacolinha plástica, logrou localizar em seu interior, os entorpecentes indicados na auto de exibição, razão pela qual foi preso em flagrante delito.

Consta mais que o Guarda Municipal Jesuíno Honório Pereira realizou a abordagem do adolescente Kayque Torres (com 17 anos de idade à época dos fatos) e de Alexandre Martins Cardoso, tendo, após revista pessoal nos dois, localizado em poder do adolescente Kayque a quantia de R\$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos). Alexandre Martins Cardoso, ao ser indagado a respeito do fato, confirmou que foi até a Praça, local conhecido como ponto de venda de drogas, para adquirir entorpecente do acusado pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais), pois é usuário de drogas há alguns anos, mas, com a abordagem da Guarda Municipal, a aquisição não ocorreu.

O acusado foi notificado (fls. 215), nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, e apresentou defesa prévia (fls. 243/244).

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 05/196), foi recebida em 28 de maio de 2021 (fls. 249/252).

O réu foi citado (fls. 300).

No curso da instrução, houve a inquirição de três testemunhas (fls. 321/323) e o interrogatório do réu (fls. 324).

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 319/320) requereu a condenação do réu como incurso no crime de tráfico de entorpecentes.

A Defesa (fls. 326/332) arguiu a ilicitude da prova, consistente na busca pessoal e apreensão da droga e todos os atos dela decorrentes, por terem sido praticados em decorrência de investigação por guardas civis, pleiteou a absolvição sob o fundamento de que não houve qualquer prova de que o acusado estivesse cometendo o

ilícito, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e, em caso de condenação, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 05), trazendo consigo, acondicionada em uma sacola plástica, o qual veio a dispensar, porções de cocaína e maconha, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 190/192) descreveu que o material apreendido consistia em:

(a) item 1: 27 microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", dotados de tampa própria, encerrando porção de material sólido particulado, com massa bruta de 38,28 gramas e massa líquida de 3,6 gramas, no qual foi detectada a presença da substância cocaína, substância entorpecente de uso proscrito, listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - lista F1.

(b) item 2: 11 invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip"), encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, com massa bruta de 32,23 gramas e massa líquida de 9,26 gramas, no qual foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), substância psicotrópica de uso proscrito, listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - lista F2;

Ainda que o réu tenha negado que estava na posse das substâncias entorpecentes apreendidas, e, ainda, que não estava a vendê-las no local, sua versão restou isolada nos autos.

Os guardas municipais declinaram, de forma firme e uníssona, que estavam em patrulhamento, quando se dirigiram ao local dos fatos, após receberem notícia - transmitida via sistema de informações (Cecom) - de que havia indivíduos, na praça pública, praticando o tráfico de drogas.

Nesse passo, discorreram que se depararam com três pessoas, sendo que puderam avistar que um dos indivíduos, que veio a ser identificado como Jonathan, estava com uma sacola branca em suas mãos que fora jogada ao solo ao empreender fuga, em que vieram a ser encontradas as dezenas de porções de tóxicos.

Mencionaram que por suspeitaram que havia algo ilícito, inclusive ante a notícia da prática de crime no local, foram no encalço dos indivíduos, vindo o agente público Bruno a deter o acusado, que admitiu a posse das drogas e a traficância, enquanto que Jesuino procedeu a custódia de Kayque.

Apontaram, ainda, que o terceiro indivíduo, chamado Alexandre, informou ter ido ao local para adquirir uma porção de crack pela quantia de R\$ 5,00, restando corroborada que se estava diante da prática de crime.

Nesse panorama, ante a quantidade de porções de entorpecentes e a forma de acondicionamento, em porções distintas, em invólucros individuais vedados e a diversidade de espécies (cocaína e maconha), aliado a circunstância de que o local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes e de que havia uma pessoa efetuando a compra de uma porção de "crack", depreende-se que as drogas se destinavam a venda ou entrega a consumo de terceiros.

Ainda que o réu tenha negado ser o possuidor da sacola com entorpecentes, sua versão restou isolada nos autos, vez que, conforme informado pelas testemunhas, trazia ela em suas mãos e tentou dela se desvencilhar para não ser incriminado, sabedor do conteúdo ilícito que havia em seu interior.

Cabe salientar, nesse passo, que os fatos foram narrados pelos guardas municipais de modo coerente e harmônico, inexistindo qualquer elemento de convicção que faça crer que eles falsearam a verdade para prejudicar o acusado.

Convém destacar que a circunstância do agente ser considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Em consequência, descabida a pretendida desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Em que pese o sustentando pela defesa, a atuação dos guardas municipais pautou-se pela legalidade, incorrendo qualquer nulidade na prisão em flagrante do acusado e na apreensão dos entorpecentes.

Nada impede que os guardas municipais, como assiste à qualquer do povo (artigo 301, CPP), deparando-se com a situação de flagrância, procedam a prisão do autor do delito.

Conforme a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "(...) inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito (...)" (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Ainda que assim alegado pela defesa, não houve atuação dos guardas municipais como polícia judiciária, nem houve qualquer investigação da prática de tráfico de drogas. Os agentes públicos, no exercício de suas atividades regulares, em patrulhamento preventivo (artigo 3º, da Lei 13.022/2014), limitaram-se a deslocar-se a uma praça pública, local em que havia notícia de que crimes estariam ocorrendo, e, ao ser constatada a prática delitiva, proceder a prisão em flagrante e encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia (artigo 5º, XIV, da Lei 13.022/2014).

Nos moldes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Não há circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da reprimenda. O réu não possui tecnicamente antecedentes criminais (fls. 203/205), e o delito fora cometido com dolo normal à espécie.

O réu possuía, na data dos fatos (15/03/2021), idade inferior vinte e um anos

(fls. 25), motivo pelo qual reconheço a existência de circunstância atenuante em seu favor, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Inviável, no entanto, a alteração da pena, vez que não é possível fixa-la abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ.

Não há que se falar em incidência, no caso em exame, da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pelo crime ter sido em praça pública. Conforme já decidido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem." (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

De outro lado, a pena deve ser reduzida, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, vez que preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena.

Convém registrar, consoante lição do professor Renato Brasileiro de Lima, que "a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização" (Legislação Criminal Especial Comentada - Volume Único, 7ª edição, 2019, ed. Juspodivm, pág. 1204).

É o caso do acusado, o qual é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica exclusivamente à atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O réu foi flagrado com pequena quantidade de drogas, o que sugere que fornecia para um numero reduzido de pessoas.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em especial a pequena quantidade de drogas, reduzo-a no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis dias-multa).

O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, conforme entendimento sedimentado pelo STF (HC 118.533/MS, Tribunal Pleno, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe-199 16-09-2016) e STJ (Pet 11.796/DF, 3ª Seção, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 29/11/2016).

De outro lado, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que o STF julgou inconstitucional a proibição em abstrato de sua concessão, constante no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso exame, estão presentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal. A pena não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (a) uma pena de prestação de serviços à comunidade (artigo 46, do Código Penal), a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução; (b) uma pena de prestação pecuniária (artigo 43, inciso I; e 45, § 1º, do CP), consistente no pagamento da importância de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu JONATHAN GABRIEL DE CASTILHO SOUZA, RG nº 57666558, filho de Thiago de Castilho Souza e

Regina Santos da Silva nascido em 03/03/2003, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, SUBSTITUINDO a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pena de prestação pecuniária, consistente no pagamento da importância de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, ambas a serem indicadas, oportunamente, pelo Juízo da Execução Criminal; e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restrita de direitos será convertida em pena privativa de liberdade e poderá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Considerando a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03, cuja exigibilidade fica suspensa, vez que beneficiário da justiça gratuita (fls. 249/252, item "1").

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 14 de abril de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito